

1500627-51.2020.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... características da contabilidade do tráfico e mais a quantia de R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em dinheiro, totalizando R\$ 1.120,00 em notas de diversos valores (típico do tráfico de rua).

Nessa mesma ocasião foi constatado que a motocicleta por ele conduzida possuía sinais de identificação adulterados, sobretudo os caracteres da placa, fato este que era de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500627-51.2020.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500627-51.2020.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2197153/2020 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 12938123 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 1162/20/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2197153 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06; e) no art. 180, "caput", do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do art. 69, também do Código Penal.

Segundo consta na denúncia (fls. 120-124), no dia 11 de agosto de 2020, por volta das 22 horas, na Rua Cel. Frederico Martins, altura do nº 120, centro; e na Rua

Buri, 99, casa, Vila São Paulo, ambos neste Município e Comarca de Capão Bonito/SP, RAFAEL trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 1 porção de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), com massa bruta total de 4,78 gramas; 5 porções de "cocaína", com massa bruta total de 3,58 gramas; e 1 porção de "cocaína" com massa bruta de 15,41 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 1).

Consta, também, que na mesma circunstância de tempo, na Rua Cel. Frederico Martins, altura do nº 120, centro, neste Município e Comarca de Capão Bonito/SP, RAFAEL conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crimes, consistente em uma motocicleta HONDA/CB250 F Twister, cor vermelha, ano 2019, com sinais identificadores adulteradores, ostentando placa EEJ-7968, de Capão Bonito/SP (FATO 02).

De acordo com o Ministério Público, por ocasião dos fatos, RAFAEL utilizava e conduzia em proveito próprio a motocicleta acima descrita, com a placa adulterada por terceiro não seguramente identificado, ciente de que se tratava de bem de origem criminosa.

Ocorre que uma guarnição da polícia militar que realizava patrulha de rotina avistou o increpado e deliberaram pela abordagem, pois havia notícias de que ele estava envolvido com o tráfico de drogas. Realizada a abordagem, os policiais localizaram em poder dele quatro "pinos" de cocaína e a quantia de R\$ 590,00 (quinhentos e noventa reais) em espécie. Indagado a respeito, RAFAEL informou que possuía mais drogas em sua residência, local em que foi encontrado um "pino" de cocaína; uma porção de "maconha" e outra de cocaína, conforme acima descrito. Além dos entorpecentes, os agentes públicos encontraram petrechos para o comércio ilícito de entorpecentes (peneira de metal, um prato de vidro e sacos plásticos), além de uma caderneta com anotações características da contabilidade do tráfico e mais a quantia de R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) em dinheiro, totalizando R\$ 1.120,00 em notas de diversos valores (típico do tráfico de rua).

Nessa mesma ocasião foi constatado que a motocicleta por ele conduzida possuía sinais de identificação adulterados, sobretudo os caracteres da placa, fato este que era de conhecimento de RAFAEL.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 131-134, seguindo-se a regular citação do réu (fl. 153), com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 223-232).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 298-308). A Defesa requereu novamente a instauração de incidente de dependência toxicológico, a absolvição, ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para o art. 28, da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a fixação da pena no mínimo legal, com os consectários daí decorrentes. Em relação ao delito de receptação, informa que o bem foi financiado em nome do tio do réu e o parcelamento vinha sendo regularmente quitado, pelo que não há crime (fls. 312-334).

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração dos delitos de tráfico de entorpecentes e receptação.

Preliminarmente, registre-se que o requerimento de instauração de dependência toxicológica foi devida e fundamentadamente indefiro por ocasião da audiência de instrução (fls. 270-271). Assim, por se tratar de reiteração de questão já decidida, não será analisado em sentença.

No mais, não se verificam outras questões preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes (FATO 01)

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06-07), auto de exibição e apreensão (fls. 09-11), laudo de constatação preliminar (fls. 22 e 23-24), laudo de exame químico-toxicológico positivo para maconha e cocaína (fls. 193-196 e 197-200), laudo pericial realizado nos objetos apreendidos, constatando resquícios de cocaína e maconha (fls. 286-289) e pela prova oral colhida em juízo. Em relação à autoria, de se considerar que o réu foi preso em flagrante delito e na fase policial, se reservou no direito de somente prestar esclarecimentos sobre os fatos em juízo. (fls. 04). Interrogado em juízo disse que: é usuário de entorpecente; tirou a moto no nome de um tio, pois não conseguiu financiar em seu nome; a placa o depoente perdeu; achou a placa na beira da estrada e colocou por baixo no mesmo dia; mas a moto é legal; o dinheiro foi do saque do auxílio-emergencial; não tem comprovante do pedido da placa no Detran; não havia caderno na residência do depoente; a moto estava no nome do tio, por parte de mãe.

A testemunha, Fabricio Assaf, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: na noite dos fatos, por volta da 22:20 horas, realizava patrulhamento de rotina em companhia do colega de farda Trindade; se depararam com o autuado conduzindo uma motocicleta e resolveram abordá-lo para averiguação porque já tinham notícias de que ele estava atuando no tráfico de drogas; procederam a revista pessoal no autuado e terminaram por encontrar em poder dele quatro pinos de pó branco semelhante à cocaína, R\$ 590,00 reais em dinheiro e um celular; ao procederem à checagem da motocicleta conduzida pelo autuado constataram também que sua placa provavelmente se encontra adulterada (substituída à parte numeral), razão pela qual as pesquisas apontavam veículo diverso; inquirido ele acabou admitindo que possuía mais drogas em sua casa; com autorização de sua avó, realizaram a checagem no imóvel e encontraram mais um pino de cocaína, uma pequena porção maconha e outro tanto de pó branco semelhante à cocaína ainda não dividido em porção para venda, localizaram também mais R\$ 530,00 em notas miúdas e outros apetrechos habitualmente utilizados na preparação de porções de drogas para venda (peneira, prato e saquinhos plásticos), além de uma caderneta com anotações características da contabilidade do tráfico de drogas; embora o autuado tenha alegado se tratar de mero usuário de drogas, deram-lhe voz de prisão e o apresentaram a delegacia para providências de praxe; já conhecia o autuado de vista e reitera que já tinha informações de que ele estava, de fato, atuando no tráfico de drogas (fls. 02). Em juízo relatou que: estavam em patrulhamento e avistaram a motocicleta; já havia informações de que o réu estaria fazendo o tráfico; os usuários ligavam e ele ia entregar a droga de moto; localizaram com ele 4 pinos de cocaína e aproximadamente 500 reais; a placas da motocicleta tinha sido cortada e os números não eram do veículo, apenas as letras; o réu disse que era usuário e que tinha mais droga na sua casa; na residência do réu encontraram mais drogas, petrechos e cadernos de anotações com nomes de pessoas que estavam devendo pra ele; na casa havia mais uma quantia de 500 reais; ao que se recorda o réu informou que estava desempregado; depois do fato não se recorda de novo envolvimento dele com o tráfico.

A testemunha, Matheus Donini Trindade, policial militar, ouvido em solo policial, disse que: na noite dos fatos, por volta da 22:20 horas, realizava patrulhamento de rotina em companhia do colega de farda Assaf; se depararam com o autuado conduzindo uma motocicleta e resolveram abordá-lo para averiguação porque já tinham notícias de que ele estava atuando no tráfico de drogas; assim, procederam a revista pessoal no autuado e terminaram por encontrar em poder dele quatro pinos de pó branco semelhante à cocaína, R\$ 590,00 reais em dinheiro e um celular; ao procederem à checagem da motocicleta conduzida pelo autuado constataram também que a placa que ela ostentava provavelmente se encontra adulterada (substituída à parte numeral), razão pela qual as pesquisas apontavam veículo diverso; ao ser inquirido ele acabou admitindo que possuía mais drogas na sua casa; com autorização da avó de RAFAEL (Maria), realizaram a checagem no imóvel e encontraram mais um pino de cocaína, uma pequena porção maconha e outro tanto de pó branco semelhante à cocaína ainda não dividido em porção para venda, localizaram também mais R\$ 530,00 em notas miúdas e outros apetrechos habitualmente utilizados na preparação de porções de drogas para

venda (peneira, prato e saquinhos plásticos), além de uma caderneta com anotações características da contabilidade do tráfico de drogas; diante disso, embora o autuado tenha alegado, a princípio, se tratar de mero usuário de drogas, deram-lhe voz de prisão e o apresentaram nesta delegacia para providências de praxe; informa que já conhecia o autuado de vista e reitera que já tinha informações de que ele estava, de fato, atuando no tráfico de drogas, e por fim, informa que o autuado acabou confessando que estava traficando há pouco tempo. (fl. 03).

Avelino Lucas, testemunha da Defesa, em juízo disse que: o réu trabalhou para o depoente como motoboy e fazia entregas; nunca teve nenhuma desconfiança em relação a RAFAEL; ele utilizava uma moto preta, twister, que era dele; ao que o depoente tinha conhecimento, RAFAEL pagava financiamento da moto; não tem ciência de problemas com policiais em relação ao veículo; depois que saiu da prisão o réu ainda trabalhou com o depoente por mais um ano; ele trabalhava das 11 às 14 e das 19 às 23, todos os dias.

Maria de Lourdes, testemunha da Defesa, em juízo disse que: é vizinha há 12 anos; sabe que o réu é motoboy; nunca observou movimentação atípica na casa do réu; o réu mora com a mãe, uma tia e um tio.

Flávio da Silva, testemunha da Defesa, disse que conhece o réu há uns 5 ou seus anos por prestar serviços para ele; tiveram contato na Igreja que frequentaram juntos.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem esmeradamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal”. (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que RAFAEL negou que fazia a comercialização das drogas, sendo apenas um mero usuário.

Ocorre que a testemunha Fabrício, em juízo esclareceu já ter recebido denúncias dando conta de que o réu estava envolvido com o tráfico de entorpecentes; os usuários pediam por telefone e o réu entregava as drogas utilizando uma motocicleta. O mesmo afirmou na fase policial a testemunha Matheus.

No dia dos fatos, com RAFAEL os policiais encontraram 4 pinos de cocaína, além de dinheiro trocado. Na residência do réu encontraram outro pino de cocaína, 1 porção de maconha (4,78g) e outra porção de cocaína não fracionada (15,41g). Além disso, alguns petrechos comumente utilizados no tráfico também foram apreendidos: prato de vidro, caderno com anotações, uma peneira de metal, 7 saquinhos plásticos

transparentes com fechamento do tipo "ziplock" (comumente utilizados para a embalagem de entorpecentes).

A perícia realizada no prato e na peneira indicou a presença de cocaína. Já nos saquinhos plásticos, o laudo aponta a presença de maconha (fls. 286-289). É evidente que os petrechos foram utilizados para a preparação/fracionamento de entorpecentes.

Quanto às anotações, embora a análise policial tenha afirmado não ser possível vinculá-la, com certeza, à atividade de traficância, vê-se que apontou a existência de "contas, dívidas, valores, pagamentos (...) bem como nome de diversas pessoas" (fls. 277). Anotações desse tipo são, mostra a prática forense, comuns em apreensões de droga.

Na residência o réu tinha, ainda, outra quantia em espécie que, somado ao quanto encontrado em seu poder, totalizou R\$ 1.120,00.

Nesse contexto, considerando a quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento, o encontro de petrechos com resquícios de cocaína e maconha, a existência de denúncias prévias aos policiais dando conta da traficância por parte do réu, não há como acolher o pleito defensivo de desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28, da Lei de Drogas.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

2.2 Sobre o delito de receptação (FATO 02)

Quanto à imputação de receptação da motocicleta consigo apreendida, o laudo pericial concluiu que "a placa da motocicleta está fora do padrão original. Analisando atentamente a placa, constatamos a existência de duas placas sobrepostas e fixadas com um rebite e 4 ganchos. Desmontando as placas, constatamos que o lacre do DETRAN estava rompido" (fls. 207).

As imagens do laudo mostram que as inscrições EEJ foram inseridas sobre a placa subjacente, onde consta FZK (fls. 207).

O réu argumentou que o veículo é regular e não proveniente de crime, o tendo comprado via financiamento bancário em nome do tio materno. Esclareceu que havia perdido a sua placa e, encontrando uma outra placa na estrada, a colocou por baixo para evitar a fiscalização e continuar trabalhando até que regularizasse a situação junto ao DETRAN.

Especificamente quanto à regularização junto ao DETRAN, se contradisse. Primeiro afirmou já ter solicitado, mas quando questionado sobre o comprovante do requerimento, mudou a versão e disse que ainda ia solicita junto ao órgão.

É certo que com a resposta à acusação o réu apresentou o documento do motociclo em nome José Rosalvo de Souza Oliveira (fls. 235). E comprovou que o proprietário é, de fato, seu parente com a cédula de identidade de José Rosalvo e sua própria certidão de nascimento. De fato, os avós de RAFAEL são os genitores de José Rosalvo. O chassi 9C2MC4410KR001888 apontado no documento é, verdadeiramente, o chassi apontado no laudo pericial. A placa original da motocicleta é EEJ-9042. Ainda que não tenha trazido uma cópia efetiva do contrato de financiamento, no bojo de suas alegações finais (fls. 331-332) indica a Cédula de Crédito Bancário em nome de seu tio e na descrição do bem financiado está a motocicleta. Não constam a placa ou o chassi, mas as informações são compatíveis com o modelo da motocicleta em questão.

A versão do réu de que colocou uma placa por baixo da original perdida é, portanto, compatível com as circunstâncias apuradas nos autos.

Não está suficientemente demonstrado, entretanto, que a motocicleta seja produto de ilícito, requisito para a caracterização do delito de receptação.

Não há dúvidas de que RAFAEL cometeu infração de trânsito gravíssima, como destacado pelo Ministério Público, porém as considerações do Parquet acerca de possível estelionato na aquisição da motocicleta exigiriam maior dilação probatória, embora façam sentido.

Da análise dos depoimentos e das demais provas dos autos, extrai-se não haver prova suficiente da materialidade delitiva, porquanto não demonstrada a origem ilícita do bem. De rigor a absolvição do réu quanto a imputação.

2.3 Tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade

O réu, de forma consciente e espontânea, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 1 porção de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), com massa bruta total de 4,78 gramas; 5 porções de "cocaína", com massa bruta total de 3,58 gramas; e 1 porção de "cocaína" com massa bruta de 15,41 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Está preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA nas penas do art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

2.4 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.4.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida cocaína e maconha. A apreensão de dois tipos de entorpecentes deve ser considerada mais grave, especialmente pelo maior potencial viciante da cocaína. É negativa a circunstância, portanto.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 1 porção de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), com massa bruta total de 4,78 gramas; 5 porções de "cocaína", com massa bruta total de 3,58 gramas; e 1 porção de "cocaína" com massa bruta de 15,41 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A quantidade já enseja maior reprovação.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por intermédio dos legisladores.

Desse modo, tendo em vista que as circunstâncias descritas no art. 42, da Lei 11.343/06 e 59, do Código Penal, somadas, totalizam dez distintas, a serem valoradas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceram-se quatro circunstâncias como negativas (a quantidade e a natureza da substância), acresço ao piso 2/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes a serem consideradas. Tem-se que o réu, embora tenha se dito usuário, confessou aos policiais, inclusive, que possuía mais drogas na residência. Por isso, reconheço a atenuante da confissão e atenuo a pena em 1/6, passando na fase intermediária para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e ao fato de não integrar organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa.

2.4.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão), o fato de o réu não ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2.4.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos, satisfazendo o requisito objetivo. Além disso, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe foram desfavoráveis. Sua conduta não se mostra incompatível com a vida em sociedade, já que o crime não afrontou a integridade física de outrem, pelo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP), em entidade a ser estabelecida pelo juízo da execução, pelo prazo da condenação e prestação de serviço e a prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

2.4.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.4.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação

0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo. Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (FATO 01) às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 194 dias-multa;.

b) ABSOLVER o réu RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA da acusação de prática do delito previsto no art. 180, caput, do CP (FATO 02), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos.

FIXO valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a prisão preventiva, pois o réu foi condenado a pena a ser cumprida em regime aberto e a custódia cautelar seria mais rigorosa do que o próprio cumprimento da reprimenda.

O réu poderá recorrer em liberdade.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

DECRETO o perdimento dos valores apreendidos às fls. 09 por ser produto de

atividade criminosa. Consigne-se que o documento de fls. 284 comprova a realização de compra no valor de R\$ 600,00 e não o saque da importância, situação que ofereceria justificativa ao menos parcial para as quantias apreendidas.

AUTORIZO, por outro lado a restituição:

i) do capacete

ii) da motocicleta apreendida, mediante a apresentação de comprovante de regularização perante o DETRAN.

DETERMINO a destruição dos demais bens apreendidos.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;

b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);

c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;

d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);

e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;

f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA